

제62회 변리사 2차 시험 『상표법』 총평

- 최지환 변리사 -

변리사 2차 수험생 여러분, 안녕하세요.

저는 메가변리사 상표법 전임 최지환 변리사입니다.

이들간 고된 시험을 마치신 모든 수험생 여러분, 진심으로 수고 많으셨습니다.

올해 상표법 문제는 정말 높은 난이도로 출제되었다고 생각합니다.

문제의 길이도 정말 길었고, 검토해야 하는 논점도 많은 편이었습니다.

먼저, 이번 [문제-1]의 출제는 여러 측면에서 적절성을 의심할 여지가 있다고 생각합니다. 그 이유는 아래와 같습니다.

① 문제에 주어진 조건이 법률에 어긋납니다.

다들 아시겠지만, 단체표장에 대해서는 통상사용권을 설정하는 것이 불가능한데(法97조5항-法95조2항), 문제에서 단체의 조합원에 대해 ‘통상사용권자’라는 지위를 임의로 부여하고 있습니다.

물론 특허법원 판결에서 조합원에 대한 통상사용권자의 지위를 인정하고 法119조1항2호를 적용한 바 있긴 하지만, 사법 작용이 법률의 문언을 벗어난 해석을 하는 것은 원칙적으로 허용되지 않으므로, 위와 같은 해석은 비판받아 마땅한 것인데, 법률의 기본소양을 평가하는 변리사 시험에서 명백하게 법문에 반하는 사항을 조건으로 제시하고, 이를 전제로 문제를 풀이하도록 요구하는 것은 부적절한 것이라고 생각합니다.

[문제 조건의 부적절성과 별개로, 문제에 ‘통상사용권자’라고 명시한 이상, 이를 통해 출제자가 法119조1항2호의 적용을 유도하고 있음을 파악하고, 통상사용권 설정이 원칙적으로 불가능하다는 점을 지적한 뒤 - 특허법원 判例에 따를 때 119조1항2호를 적용하는 방식으로 대응하는 것이 수험생 입장에서는 지혜로운 전략이었을 것입니다.]

② 하급심에서 확정된 사례를 시험에 출제하는 것이 과연 변리사 시험의 제도적 취지에 부합하는지 의문입니다.

저도 방어적인 차원에서 최종정리 강의와 실전GS B2형 강의에서 본 판례에 대해 설명하긴 하였으나, [문제-1]의 모티브가 된 “광천김” 지리적 표시 단체표장등록 취소심판 사건(2022허5690)은 특허법원에서 확정된 사건입니다(심지어 동일 권리에 대한 무효사건은 대법원 상고심 계속중임).

물론 [문제-1]은 상표법 규정만으로도 풀이 가능한 문제이긴 하나, 해당 판결의 구체적인 사실관계를 학습한 수험생과 그렇지 않은 수험생 간에 명백한 유불리를 초래하는 문제였다는 점은 부인할 수 없습니다. 특히 변리사 시험이 법률의 기본 소양과 조문·판례의 원칙적 이해를 평가하는 시험이라는 점을 고려할 때, 하급심에서 확정된 사례를 모티브로 삼아 시험 문제를 구성하는 것이 타당한 방향인지에 대한 검토가 필요하다고 생각합니다.

분명 2025년 변리사 시험을 기점으로, 앞으로 많은 수험생들은 ‘내가 모르는 하급심 사례가 나오면 어쩌나’하는 불안감으로 학습이 불필요한 하급심 사례들까지 학습하는 일들이 비일비재해질 것입니다.

출제위원들도 출제 방향에 대해 고심이 많았을 것이라고는 생각합니다. 요즘 수험계에서는 중요한 대법원 판례를 모두 모의고사화 하고 있고, 많은 수험생분들이 꼼꼼하게 판례를 정리하고 있기에 변별력 있는 문제를 출제한다는 것이 쉽지 않다는 점에 대해서는 매우 공감합니다. 하지만 변별력을 만드는 다른 방법도 없는 것은 아니기에, 시험의 변별력을 하급심 사례를 통해 만드는 것이 옳은 방향인지에 대해서는 시험 주최측에서 고민해봐야 할 문제라 생각합니다.

이하에서는 각 문제에 대하여 핵심 취지와 총평을 안내 드리겠습니다. [이하 총평은 각 문제의 핵심 논점과 결론을 간략히 정리한 것으로, 구체적인 목차 구성 및 사안 포섭은 사례집 개정시에 반영해드릴 예정인 점 참고 부탁드립니다.]

I. 문제-1

문제 유형	논점추출형 (지리적 표시 단체표장)
예상 출제취지	1. 지리적 표시 단체표장의 출원과정에서의 실체적·절차적 쟁점사항 검토 2. 지리적 표시 단체표장권의 하자(취소사유)에 대한 검토
난이도	상
각 설문별 핵심쟁점	
설문(1) [2025 실전GS A형 8회 문3-(2), B1형 3회 문2-(1), B2형 4회 문4-(1)]	[지리적 표시 단체표장 일반론] [제출서류 ① - 정관(法36조3항)] (1) 法36조3항 - 출원서에 '단체표장의 사용에 관한 사항을 정한 정관'을 첨부해야 함 (2) 法54조5호 - 유의사항으로서, 정관을 통해 정당한 단체원의 가입을 금지하여서는 안 됨 (3) 사안 [제출서류 ② - 지리적 표시 정의 합치 증명서류(法36조5항)] (1) 法36조5항 (2) 사안
설문(2) [2025 실전GS A형 8회 문3-(2), B1형 3회 문2-(1), B2형 4회 문4-(1)]	[선결적인 검토] (1) '지리적 표시'의 정의(法2조1항4호) (2) 사안 - "대천김"이 '지리적 표시'의 정의에 부합하는지 여부 - 法2조1항4호 요건 포섭 [심사의 결과] (1) 정의규정 위반 거절이유 - O 1) [표장의 문제] - 지리적 출처를 나타내는 것과 무관한 "K-STAR"가 포함되어 있어 정의규정 위반 2) [지정상품의 문제] - 정관에 나타난 '조미구이 김'과 지정상품이 상이함 (2) 출원인 적격 위반 거절이유 - O 1) [法3조2항괄호] - 18. 7. 18. 개정법에서 '만' 요건 삭제 2) [사안 - B 단체원 관련] - 유통하는 업자가 포함되어 있어도 문제되지 않음 3) [사안 - C 단체원 관련] - C가 포함된 것은 출원인 적격 위반임 (3) 法33조1항3호, 法34조1항12호전단 - X 1) [法33조3항] 2) [사안] - 상품이 적절하게 보정되는 경우 문제되지 않음 (4) 法34조1항10호, 14호 - '타인'이 아니므로 문제되지 않음 [간단히만 검토] (5) 소결 - 표장, 지정상품으로 인해 '정의규정' 위반 & 출원인 적격 위반 거절이유가 지적될 것 [등록을 위한 조치] (1) 표장 보정 1) [심사기준] - 지리적 표시를 제외한 나머지를 삭제하는 것은 요지변경으로 보지 않음 (테마p.363) 2) [사안] - 지리적 출처와 무관한 "K-STAR"를 삭제하여 표장을 "대천김"으로 보정해야 함 (2) 지정상품 한정보정 - "김, 조미 김, 구이 김"을 정관에 나타난 "조미구이 김"으로 보정해야 함 (3) 단체원 C 탈퇴 및 정관변경 - C를 탈퇴시킨 뒤, 수정된 정관을 보정기간 내에 제출(法43조1항)
설문(3) [2025 실전GS B2형 4회 문4-(1)]	[法119조1항2호] (1) 法97조5항 & 法95조2항 - 단체표장권에는 사용권 설정이 불가함 (2) 사안 - 특허법원 판결 및 문제의 조건에 따라 '사용권자'의 지위가 인정된다면, ① A가 지정상품이 아닌 '김자반, 김밥김'에 "대천김"을 사용하는 행위, ② B가 순천에서 김을 생산하면서 "대천김"을 사용하는 행위, ③ F가 지정상품이 아닌 '구운 감태'에 "대천김"을 사용하는 행위로 인해 法119조1항2호에 해당

[法119조1항7호(가)목]

- (1) 法119조1항7호(가)목 의의, 취지
(2) 사안 - ① A가 지정상품이 아닌 '김자반, 김밥김'에 "대천김"을 사용하는 행위, ② B가 순천에서 김을 생산하면서 "대천김"을 사용하는 행위, ③ D가 부속서에 나타난 조건에 위반하여 외국산 참기름, 정제염 및 맛소금으로 만든 상품에 "대천김"을 사용하는 행위 ④ F가 지정상품이 아닌 '구운 감태'에 "대천김"을 사용하는 행위로 인해 法119조1항7호(가)목에 해당

[法119조1항7호(다)목]

- (1) 法119조1항7호(다)목 의의, 취지
(2) 사안 - 조합원이 아닌 E가 무단으로 지리적 표시를 사용하고 있음에도 불구하고, 甲이 이를 알고 고의로 적절한 조치를 취하지 않았으므로 法119조1항7호(다)목에 해당

[法119조1항8호(가)목]

- (1) 法119조1항8호(가)목 의의, 취지
(2) 사안 - '조미구이 김'이 아닌 '구운 감태'를 생산하는 F는 단체원으로서 가입될 수 없는데[정관 49조], 단체의 가입을 허용하였으므로 法119조1항8호(가)목에 해당

[결론]

인용심결 예상 & 심결이 확정된 때부터 장래를 향해 소멸(法119조6항)

II. 문제-2

문제 유형	판례복합형 (MONO HOUSE 判例 + speedo 判例 + 장우동 判例)
예상 출제취지	1. 침해죄 관련 일반론 검토 2. MONO HOUSE 判例 & speedo 判例 검토 3. 장우동 判例 및 관련 법리 검토
난이도	중하
각 설문별 핵심쟁점	
설문(1) [2025 실전GS B2형 2회 문1-(3)]	[침해죄(法230조)의 의의] [침해죄 관련 규정] (1) 法230조 관련 성립요건 - 상표권/전용사용권 침해 & 형법상 원리에 따라 '고의' 요구 (2) 몰수(法236조) (3) 양벌규정(法235조)
설문(2) [2025 실전GS A형 1회 문2-(1), A형 3회 문4-(1)]	[乙이 상표권자로서의 지위를 갖는지 여부] (1) 이전 등에 관한 등록의 효력(法96조1항1호) (2) 상표권 이전의 효력발생 判例 - ① 이전에 관한 합의 & ② 이전등록 [MONO HOUSE 判例] (3) 사안 - 이전에 관한 합의가 없었으므로, 이전의 효력 발생 X [乙이 일반 수요자에게 판매한 행위] (1) 상표의 사용 및 침해성립여부 검토 - '상품' 개념 부합 & 法2조1항11호(나)목 O & 침해 O (2) 고의 인정여부 - 간단하게 포섭 (3) 소결 - 침해죄 성립 O [乙이 거래처에게 사은품으로 제공한 행위] (1) 상표법상 '상품'의 개념 (2) 일부 무상으로 제공한 경우의 취급 등 判例 (3) 사안 - '상품' 개념 부합 & 法2조1항11호(나)목 O & 고의 O → 침해죄 성립 O [乙이 판매 목적으로 소지한 행위] (1) 法108조1항4호 (2) '간접침해'에 침해죄의 책임을 물을 수 있는지 여부 - 명시적인 判例 X & 특허법 관련 判例 (3) 소결 - 침해죄가 성립된다고 보기 어려울 것 [COA 判例 등의 취지에 비추어 볼 때 성립되는 것으로 포섭하는 것도 가능]
설문(3) [2025 실전GS B2형 4회 문4-(2)]	[丙이 통상사용권자의 지위를 갖는지 여부] (1) 法100조1항1호 (2) 사안의 경우 - 등록을 하지 않았어도 통상사용권자의 지위를 가짐 [甲의 상표권을 침해하는 것인지 여부] (1) 法97조2항 (2) 통상사용권에 기해 상표를 사용하는 경우 判例 - 상표권 침해 불인정 (3) 사안 - 상표권자에게는 '통상사용권'을 주장할 수 있으므로, 침해 X [丁의 전용사용권을 침해하는 것인지 여부] (1) 法95조3항 (2) 대항할 수 없는 '제3자'의 의미 判例 - 장우동 判例 (3) 사안 - (i) 21.2.1.~24.1.31. 사이 기간은 전용사용권 발생 X → 침해 X, (ii) 24.2.1. 이후 행위 관련해서는 전용사용권자 丁은 대항할 수 없는 '제3자'이므로 전용사용권 침해 O

III. 문제-3

문제 유형	논점추출형
예상 출제취지	1. 상표 유사판단과 관련하여 ‘비유사’ 주장 의견의 요지 [실무형 성격 有] 2. 심결취소소송 ‘소의 이익’ 관련 airfryer 判例의 적용 3. 상표 공존동의제도 적용에 관한 문제
난이도	중상 [객관적인 난이도는 높지 않으나, 시험장에서 출제자의 의도를 파악하기가 어려웠을 것으로 예상되어 ‘중상’으로 평가함]
각 설문별 핵심쟁점	
설문(1)	[法34조1항7호 관련 일반론 & 요건 검토] [상표 유사판단 원칙] [상표 비유사 주장 요지 ① - 호칭 비유사] (1) 외관, 호칭, 관념 중 하나가 유사하여 출처혼동염려 있는 경우 判例 (2) 명확히 출처혼동을 피할 수 있는 경우 判例 (3) 문자상표에 관한 判例 - ‘호칭’이 중요 (4) 사안 - 문자상표에서 ‘호칭’이 중요 & 2음절로 짧아서 1음절 차이도 비중이 적지 않음 주장 [상표 비유사 주장 요지 ② - 구체적 출처혼동 염려 없음] (1) 유사판단에 관한 학설 - 일반적 출처혼동설 vs 구체적 출처혼동설 (2) 구체적 출처혼동 염려 없는 경우 判例 - ROLEX 判例 (3) 사안 - 당해 상품을 둘러싼 거래실정을 고려할 때, 구체적·개별적 출처혼동 염려 없음 주장 [※ 간략 Comment] 출제자는 1996년에 선고된 대법원 판결(96후153, 96후191 판결 - ROLEX 판례와 동일 법리) 사안에 기초하여 사실관계를 구성한 것으로 보이는데, 사실관계를 문제로 차용하는 과정에서 다소 부적절한 설정의 변경이 있었다고 생각합니다. 실제 판례에서는 선등록상표가 “POLA” (비유명상표)이고 후출원상표가 “POLO” (저명상표)였고, 후출원상표가 널리 알려진 반면 선등록상표는 거의 알려진 바 없다는 점을 근거로 공존이 가능하다는 결론을 내렸습니다. 그리고 저명상표와 비유명상표의 공존을 인정한 대법원 사례들은 대부분 선행상표가 비유명상표이고 후행상표가 저명상표인 경우로서, 이러한 사안에서 ‘구체적 출처혼동 염려’가 없다고 보아 공존이 가능하다고 판단한 것입니다(판례집에서 학습한 “포타칩” 사건도 유사한 사안). 그러나 이번 문제는 선등록상표가 저명하고 후출원상표가 저명하지 않은 설정인데, ‘구체적 출처혼동 염려가 없다’는 논리를 통해 공존 가능성을 주장해보라는 취지로 사실관계를 구성하고 있습니다. 이는 실무적인 관점에서 논리적으로 적절하지도 않은 측면이 있고(후행 권리자가 선행 권리가 저명하다고 주장하면서 비유사한 것으로 인정해달라는 주장을 하는 것은 매우 부자연스러움), 공존 법리를 적용한 판례들과 사실관계의 맥락이 상이하다는 점은 부인할 수 없습니다(ROLEX 사건의 경우에도 후행상표인 Rolens 역시 어느 정도 인식도를 얻고 있었다는 점이 고려된 사안임). 물론 배경이 크고 다른 논점을 적을 것이 없기 때문에 ‘구체적 출처혼동 염려 없음에 따른 공존 가능성’을 주장하는 것을 답안에 적었어야 한다는 점에 대해서는 이견이 없으나, 해당 사실관계 설정이 원 판례의 취지를 온전히 반영하지 못하고 있음은 지적할 여지가 있는 부분이라 생각합니다.
설문(2)	[심결취소소송에서 요구되는 ‘소의 이익’] [상표출원 ‘취하’의 의미] - 출원이 처음부터 없었던 것으로 보게 만드는 행위 [判例] - airfryer 判例 [사안] - (1) 출원이 처음부터 없었던 것으로 되므로, 존재하지 않는 출원에 대한 거절결정을 유지하는 심결 역시 위법하게 되지만, (2) 이 심결을 취소할 법률상 이익도 사라짐 → 소 각하 판결

설문(3)	[상표 공존동의제도] (1) ‘상표 공존동의제도’의 의의 (2) 구법상 문제점 - 공존 동의제도 불인정, 判例도 ‘수요자 보호’를 위해 불인정, 일시양도 우회방안 (3) 24.5.1. 개정법 - 法34조1항7호단서 등 & 수요자 보호를 위해 동일범위 제외, 法119조1항5호의2 [乙 후출원상표가 등록될 수 있는지 여부] (1) 자신의 선행상표와의 관계 - ‘타인’이 아니므로, 法34조1항7호, 9호 등 모두 문제되지 않음 (2) 甲의 재출원상표와의 관계 - 法34조1항7호 해당 O, 특히 공존동의를 해준 사정이 있다고 하여 그 이후의 후속출원에 대한 거절이유 적용을 배제하는 규정은 존재하지 않음. (3) 소결 - 이하와 같은 조치를 취하지 않는다면 등록받기 어려움 [乙이 후출원상표를 등록받기 위한 방안] (1) 甲으로부터 공존동의를 받는 방안 - 동일 범위가 아니므로 공존동의를 받아 공존동의서를 보정서 또는 의견서에 첨부하여 제출하면 法34조1항7호단서에 따라 등록 가능 (2) 보론 - 甲 등록상표에 대한 무효심판 청구 - 乙의 상표가 저명하다면 甲의 등록상표에는 法34조1항9호, 11호 및 12호의 무효사유가 존재한다고 할 수 있고, 위 부등록사유에 대해서는 공존동의제도가 적용되지 않으므로, 甲이 공존동의를 해주지 않는다면 乙은 甲의 재출원상표에 法34조1항9호, 11호 및 12호에 근거한 무효심판을 청구하여 소멸시킨 뒤 후출원상표를 등록받는 방안도 고려 가능 (다만, 문제 전체의 취지상 간략히만 적는 것이 바람직할 것으로 예상됨)
--------------	--

IV. 문제-4

문제 유형	판례중심형 + 논점 추가 (SONY 判例)
예상 출제취지	1. '상표의 사용' 관련 SONY 判例 2. 비중요논점인 法151조의2 법조문 내용 체크 3. 질권의 등록의 효력에 관한 법조문 내용 체크
난이도	중
각 설문별 핵심쟁점	
설문(1)	[상표권 침해 일반론] [사용태양 ① - 내부 부품에 표시된 표장] (1) 표시행위(法2조1항(가)목) 의의 (2) 공산품 내부 부품에 표시된 상표의 취급 判例 (3) 사안의 경우 - '표시행위'로 인정될 수 없음 → '상표의 사용' X [사용태양 ② - 하단표면에 표시된 표장] (1) '상표적 사용'의 의미 (2) 순수한 설명적 사용의 취급 判例 (3) '상표적 사용'의 판단기준 判例 - [두문자: 상·태·주·의·경] (4) 사안의 경우 - 순수한 설명적 사용 → '상표적 사용' X [결론] - 침해 X
설문(2)	[산업재산권분쟁조정위원회 회부 관련 일반론 - 法151조의2] (1) 法151조의2 1항 의의 및 취지 (2) 法151조의2 2항 (3) 法151조의2 3항 [사안 - 조정이 성립된 경우] - 해당 심판청구는 취하 간주 & 심판절차 종료 [사안 - 조정 불성립의 경우] - 심판장은 1항에 따른 심판절차 중지결정을 취소하고 심판 재개
설문(3)	[A 은행의 지위] (1) 통상사용권을 목적으로 하는 질권에 관한 등록의 효력 - 法100조1항2호 (2) 사안 - 상표권자 甲의 동의를 받아 적법하게 설정한 것이며(法97조4항), 등록은 '제3자 대항요건'에 불과하므로, 질권자로서의 지위 인정 O [乙 및 丙의 지위] (1) 乙의 지위 - 설정 및 등록까지 마친 '통상사용권자'에 해당 O (2) 丙의 지위 - 상표권자의 동의를 받아 적법하게 이전하였다면(法97조3항), 설정 및 등록까지 마친 '통상사용권자'에 해당 O [A가 질권 행사를 할 수 있는지 여부] (1) 丙이 '제3자'에 해당하는지 여부 - 질권 설정에 관하여 양립할 수 없는 지위를 취득한 자이므로, 대항할 수 없는 '제3자'에 해당함 (2) 결론 - A는 질권을 행사할 수 없음